

1502478-64.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/04/2022

... tem o significado de que toda e qualquer união destinada à prática do tráfico ilícito de drogas caracterize o delito de associação para o mesmo tráfico, pois a união, o acordo de vontades destinado ao cometimento do comércio ilícito, sem a comprovação de uma vontade distinta, organizada no sentido de constituição de uma associação voltada ao mesmo tráfico (vontade, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502478-64.2021.8.26.0132 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502478-64.2021.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2226662/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 19742337 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

3988/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2226662 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

3988/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO FERNANDO FUZARO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

EDUARDO FERNANDO FUZARO e KLÉBER ALFREDO TORRES, qualificados, respectivamente, às págs. 6 e 7, foram denunciados como incurso nos arts. 33, "caput", 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, tendo KLÉBER ALFREDO ainda sido denunciado como incurso no art. 329, "caput", do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

"No dia 20 de agosto de 2021, por volta das 00h30min, na Avenida Guido Girol, Jardim São Domingos, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, os denunciados se associaram para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros e, nesta qualidade, EDUARDO trazia consigo 26

(vinte e seis) pinos de cocaína, enquanto KLEBER fornecia as drogas e recolhia o dinheiro proveniente do tráfico, além de trazer consigo 14 (catorze) pinos de cocaína e guardar 30 (trinta) pinos de cocaína, totalizando o peso líquido de 14,7 gramas, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 50 e laudo de constatação de fls. 52/54.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, KLEBER ALFREDO TORRES se opôs à execução de ato legal, consistente em sua prisão em flagrante delito, mediante violência contra o policial militar Emerson Rogério de Paula, funcionário competente para executá-lo.

Apurou-se que, os policiais militares durante patrulhamento avistaram dois indivíduos em uma praça, onde um entregava um objeto para o outro. Com a aproximação da viatura, ambos se separaram e seguiram caminhos opostos, o que motivou a abordagem policial.

Inicialmente, os policiais abordaram EDUARDO, sendo localizados 26 (vinte e seis) pinos de cocaína. Indagado pelos policiais, EDUARDO afirmou que o outro indivíduo era KLEBER e que este acabara de fornecer os entorpecentes e recolher valores provenientes de drogas já vendidas.

Na sequência, os policiais colocaram EDUARDO na viatura e seguiram diligência para abordagem de KLEBER, o qual ao perceber que seria abordado empreendeu fuga. Em perseguição policial, KLEBER adentrou em um bar e empurrou o balcão contra o policial Emerson Rogério de Paula, bem como desferiu socos contra ele. Após os policiais conterem o denunciado e o algemarem, foi realizada revista pessoal, sendo encontrado 14 (catorze) pinos de cocaína, anotações da contabilidade do tráfico, bem como a quantia de R\$ 177,00 (cento e setenta e sete reais). Indagado pelos policiais, KLEBER confessou que forneceu drogas aquele ponto de venda de drogas e informou que havia guardado mais entorpecentes em sua residência.

Os policiais dirigiram-se até o endereço indicado por KLEBER, sendo localizado na residência 30 (trinta) pinos de cocaína divididos em três saquinhos de com 10 (dez) pinos cada.

Para os policiais, o denunciado EDUARDO confessou que havia acabado de receber drogas de KLEBER para fins de tráfico, por sua vez, KLEBER confessou ser o fornecedor daquele ponto de venda de drogas. Na Delegacia de Polícia, ambos os denunciados negaram a prática do tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto, denunciou EDUARDO FERNANDO FUZARO como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, todos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, e KLEBER ALFREDO TORRES como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, todos da Lei nº 11.343/06 e do artigo 329, "caput", (resistência) do Código Penal, todos em concurso material, e requeiro que sejam intimados para apresentarem defesa prévia, e, depois de recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, citando-se os acusados para a audiência de instrução e julgamento, nos moldes do art. 56 da Lei 11.343/06, oportunidade na qual serão interrogados, serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, como também as da defesa, serão apresentadas sustentações orais pelo parquet e pela defesa, até final decisão condenatória, na forma do rito especial previsto na Lei 11.434/06" (denúncia de págs. 132/134).

Os acusados foram presos em flagrante delito no dia dos fatos e permanecem recolhidos até a presente data, já que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (págs. 99/101).

Citados e notificados (págs. 161/163), os acusados apresentaram as defesas prévias de págs. 167/168 e 221/224.

A denúncia de págs. 132/134 foi recebida em 22 de novembro de 2021 (págs. 174/176). Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns e, por último, interrogados os acusados (audiência de págs. 271/272 e 274).

Na fase do art. 402, do Código de Processo Penal, nada foi requerido (pág. 271).

Em seu memorial de págs. 280/285, o Ministério Público pleiteia a procedência parcial da ação penal, justificando que os acusados cometeram apenas o delito de tráfico ilícito de drogas. Ainda pleiteia a condenação de Kléber Alfredo pela prática do crime de resistência.

As Defesas, às págs. 296/298 e 303/306, pugnam pela absolvição, alegando, em

síntese, insuficiência de provas.

É relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

De fato, conforme adiante será exposto, cometeram os acusados somente o delito de tráfico ilícito de drogas, tendo Kléber Alfredo ainda praticado o crime de resistência.

Quanto ao tráfico ilícito de drogas, a materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 50 (referente a setenta pinos plásticos de "cocaína" e R\$177,00, em dinheiro e notas diversas) e dos laudos de exame químico-toxicológico de págs. 52/54 e 142/144, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de drogas.

A autoria, quanto ao tráfico ilícito de drogas, também é certa, incontroversa.

Na fase policial (pág. 6), EDUARDO FERNANDO negou a prática delitiva, alegando que tinha em seu poder somente um pino plástico de "crack", destinado ao seu próprio consumo. Não tinha outras drogas em seu poder e não conhecia Kléber. Foi agredido fisicamente pelos policiais, porém não ficou com o corpo lesionado. Não confessou o crime aos policiais.

KLÉBER ALFREDO, por sua vez, também negou a prática do crime durante o inquérito policial (pág. 7), alegando desconhecer totalmente os fatos e que não possuía drogas em seu poder. Foi agredido fisicamente pelos policiais dentro do "Bar da Loira". Foi levado pelos agentes da lei a um imóvel da rua Araraquara, porém não morava naquele local. Estava no referido bar apenas para comprar um pino de "cocaína", o qual consumiu no próprio local.

Em Juízo (gravação referente à audiência de págs. 271/272 e 274), EDUARDO FERNANDO alegou que realmente estava de posse de vinte e seis pinos de "cocaína", porém a droga não era para venda a terceiros e sim para consumo próprio. Não conhecia o acusado Kléber e nunca o havia visto até então. Comprou os 26 pinos de "cocaína" do acusado Kléber, que estava no local dos fatos, por R\$170,00 (cento e setenta reais). Nada mais sabe dizer, pois, após o momento em que foi abordado, ficou dentro da viatura. Viu que os policiais abordaram Kléber e o levaram até a casa dele. Não sabe dizer, porém, se houve apreensão de alguma coisa em poder dele. Foi a primeira vez que comprou droga de Kléber. Não conhecia os policiais e nada tem contra eles. Era usuário de "cocaína". Usa droga desde os 16 anos de idade, inclusive já ficou internado, para tratamento, duas vezes. Trabalhava em uma barbearia de um tio seu, na profissão de barbeiro, e o dinheiro usado para comprar a droga de Kléber era proveniente de seu trabalho.

KLÉBER ALFREDO (gravação referente à audiência de págs. 271/272 e 274) também negou completamente a prática delitiva, alegando que sequer conhecia o acusado Eduardo. Não estava em contato com Eduardo no momento dos fatos, embora o tenha visto na praça em que os fatos ocorreram. Informado que Eduardo disse ter comprado drogas do interrogando, negou a venda de drogas a ele. No momento dos fatos, tinha em seu poder somente dinheiro resultante de seu trabalho de eletricitista. Não tinha drogas em seu poder no momento em que foi abordado e nem sua casa. No momento dos fatos, estava no interior de um bar, tomando um refrigerante e aguardando o preparo de um lanche, momento em que policiais ali chegaram fazendo abordagem e abusando do poder. Estava "louco de pedra" (uso de "crack"), inclusive sem dormir durante três noites, e os policiais ali chegaram "dando coronhada na minha cara, dando soco na minha cara", momento em que disse a eles que não admitiria aqueles atos. Realmente jogou o balcão sobre os policiais, porém para se defender. Os policiais também chegaram "enforcando" o interrogando e bateram neste dentro do bar e após a prisão. Apanhou dos policiais das 20:00 às 23:30 horas naquele dia, cujas agressões começaram dentro do bar. Ficou machucado naquele dia, porém, durante o exame médico, não lhe deram a atenção devida. Ficou com dores durante dois meses na penitenciária, cuspiendo sangue e sem remédios. Chegou a passar por atendimento na UPA, duas vezes, em Catanduva. Não conhecia os policiais até então. Usava "crack" desde os 16 anos de idade e já ficou internado para tratamento uma vez, quando

ainda era menor de 18 anos de idade. Morava na rua Araraquara, nº 993, na data dos fatos.

A negativa de autoria apresentada por ambos os acusados, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação.

É que o POLICIAL MILITAR MAURI BORGES DE CARVALHO (gravação referente à audiência de págs. 271/272 e 274) disse que patrulhava em uma praça (local conhecido como ponto de venda de drogas), ocasião em que avistou um indivíduo passando algo a outro. Ambos os indivíduos passaram a deixar a praça em sentido opostos. Eduardo foi abordado e encontrado de posse de pinos de "cocaína", momento em que ele admitiu que ali estava vendendo drogas e que o outro indivíduo (Kléber) passou pelo local para abastecimento de mais drogas para venda e recolhimento do dinheiro proveniente das vendas das substâncias. Eduardo foi detido e posto na viatura. Em seguida, diligenciaram visando localizar Kléber, tendo localizado-o na avenida Guido Girol e defronte de um bar. No momento da abordagem, Kléber entrou no bar, momento em que ele empurrou um balcão ali existente para se desvencilhar dos policiais e correu para os fundos do estabelecimento em seguida, visando fuga. Nos fundos do bar, porém, não havia mais saída e Kléber passou a dar socos e chutes no policial De Paula (outro policial que estava na diligência). Foi necessário o uso de força física moderada no acusado. Kléber estava de posse de R\$177,00, em dinheiro, enrolados em um papel com a contabilidade da venda de entorpecentes. O acusado Kléber ainda trazia, sob a cueca, um saco plástico com mais pinos de "cocaína". Indagado, Kléber confessou que fazia a "gerência" do tráfico na praça e que havia mais drogas na casa dele, no interior da qual foram localizados mais trinta pinos de entorpecentes. Kléber também confessou ser integrante do "PCC". Não conhecia os acusados até então. Os acusados não aparentavam uso de entorpecente no momento dos fatos.

E o TAMBÉM POLICIAL MILITAR EVERTON ROGÉRIO DE PAULA (gravação referente à audiência de págs. 271/272 e 274) depôs no mesmo sentido do outro policial, confirmando, portanto, os fatos descritos na denúncia. Acrescentou que, no início das diligências, Eduardo era quem entregava algo a Kléber. Em seguida, as diligências se passaram como descrito pelo outro policial. Nunca havia abordado os acusados até então. O depoente e o outro policial não foram atingidos pelo balcão lançado pelo acusado Kléber, pois conseguiram dele se desvencilhar. Os socos deferidos por Kléber atingiram o depoente e os outros policiais da equipe, porém sem lhes causar lesões corporais. Os socos deferidos por Kléber atingiram o peito e o pescoço do depoente.

Diante das apreensões realizadas e dos relatos dos agentes da lei, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que os acusados se encontrassem, juntos, praticando a mercancia ilícita, pois, em local conhecido como ponto de venda de drogas, ambos foram vistos entregando algo um para o outro, momento em que EDUARDO FERNANDO foi abordado e encontrado de posse de vinte e seis pinos plásticos de "cocaína", embaladas de forma própria para venda e suficientes, portanto, para fornecimento a inúmeras pessoas, oportunidade em que confessou a tais agentes que havia acabado de receber as substâncias de KLÉBER ALFREDO para venda no local; EDUARDO FERNANDO ainda confessou que havia acabado de entregar o dinheiro resultante da venda de drogas a KLÉBER ALFREDO, o qual, momentos depois, também foi abordado e encontrado com catorze pinos plásticos de "cocaína" (embaladas de forma própria para venda), momento em que confessou aos policiais que atuava como uma espécie de "gerente" no tráfico de drogas e que guardava mais drogas em sua casa, situada na rua Araraquara, nº 993, nesta cidade, dentro da qual foram localizadas mais trinta porções de "cocaína", também prontas para venda e, suficientes, portanto, para fornecimento a várias pessoas.

A atitude dos acusados é típica de quem pratica tráfico ilícito de drogas e as diligências, da forma como se deram, confirmaram que as drogas encontradas em poder de ambos eram destinadas ao comércio ilícito.

Cometeram os acusados, assim, o delito de tráfico ilícito de drogas que lhe foi imputado na inicial acusatória.

O acusado KLÉBER ALFREDO ainda cometeu o delito de resistência, eis que, quando da abordagem, resistiu à ação legal dos policiais militares que participavam da

ocorrência (consistente em detê-lo em flagrante delito), na medida em que, no interior de um bar, lançou um balcão na direção dos agentes da lei e desferiu socos e chutes neles, principalmente no militar Everton Rogério, atingindo-o no peito e no pescoço, conforme depoimentos deste (Everton Rogério) e do outro policial colhidos sob o crivo do contraditório.

KLÉBER ALFREDO nega a prática delitativa e disse ter sido agredido fisicamente pelos agentes da lei, porém sua versão encontra-se totalmente isolada nos autos e, desse modo, não merece acolhimento.

O fato de os acusados eventualmente também serem usuários de substâncias entorpecentes (alegação contida nos interrogatórios policial e judicial), não permite, por si só, eventual desclassificação do delito, pois nada impede que o fornecedor de entorpecentes também faça uso das mesmas substâncias, caso em que a figura do uso é absorvida pela norma contida no artigo de lei por último mencionado.

Confira-se:

“Traficante viciado

Nada impede que responda como traficante. Nesse caso, aplica-se a norma do art. 12, absorvido o delito do art. 16 desta Lei. Nesse sentido: RT 515:466, 517:368 e 380, 555:380, 585:311 e 595:408; RJTJSP, 101:498 e 114:482; JTACrimSP, 64:38; TJRS, RCrim 1.342, RF 283:322; TJMT, ACrim 212.180, RF , 282:403; TJRS, ACrim 691069488, RJTJRS , 154:141; TJPR, ACrim 342/88, PJ, 29:241; stf, HC 69.806, 1a. Turma, rel. Min. Celso de Mello, RT 701:401 e RTJ, 151:155. Tanto é que o art. 11 desta Lei reza: 'Ao dependente que, em razão de qualquer infração penal, for imposta pena...' (grifo nosso)” (conforme Damásio E. de Jesus, Lei Antitóxicos Anotada, São Paulo : Saraiva, 4a. ed., 1999, p. 21).

Tal jurisprudência, embora se refira à lei antiga, aplica-se, obviamente, à lei atual.

Quanto à força probante do probante dos relatos dos agentes da lei colhidos durante a instrução criminal, sabe-se que os depoimentos de policiais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha.

Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou:

“Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão” (JTACrim, 10:138).

“Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT, 668:275).

As regras de experiência comum permitem a conclusão de que pessoas da comunidade que não integram os quadros policiais dificilmente se prontificam a depor contra traficantes de drogas, pois estes normalmente são pessoas perigosas, criminosas, de personalidade violenta e voltada para a prática de crimes e que causam, portanto, medo e temor às pessoas de bem, as quais, por temerem represálias, não se apresentam aos agentes do Estado para depor como testemunhas.

No que pertine às alegações de contradições ou divergências nos depoimentos dos policiais que depuseram em Juízo, observo que é comum a existência de pequenas (ou determinadas, dependendo do caso) divergências nos relatos dos agentes da Polícia Militar, porém tal é comum devido ao tempo decorrido e às inúmeras ocorrências atendidas pelos integrantes daquela Corporação, circunstâncias que podem provocar, obviamente, esquecimentos quanto a alguns detalhes das ocorrências atendidas; os policiais não têm memória fotográfica e, devido às condições pessoais de cada um, podem muito bem ter a percepção de alguns detalhes da ocorrência de forma diferente um do outro.

O que não pode ser aceito, em depoimentos de policiais (assim como nos depoimentos em geral), é a ocorrência de má-fé durante a diligência e, por via de consequência, no depoimento a ser prestado sobre ela, todavia, no caso presente, apesar das divergências verificadas quanto a detalhes do trabalho policial realizado, os

policiais Mauri e Éverton Rogério depuseram de forma coerente e seus relatos, amparados pelas apreensões realizadas e pelas circunstâncias da prisão (local de intensa traficância), nenhuma dúvida deixaram quanto ao cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas por parte de Eduardo Fernando e Kléber Alfredo; nenhuma dúvida há quanto à lisura do trabalho realizado pelos referidos policiais.

A propósito, cito trecho de V. Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP - Apelação : APL 00023099020108260374 SP 0002309-90.2010.8.26.0374, 10ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Nuevo Campos, Data de Julgamento: 23/10/2014, Data de Publicação: 24/10/2014), no qual o eminente Relator deixou assentado: "Quanto à credibilidade dos testemunhos dos policiais, é preciso anotar que não há óbice legal a que prestem depoimento, sob compromisso, sobre seus atos de ofício. Insta consignar, a propósito, que divergências de ordem secundária entre os relatos dos policiais, em especial, os apresentados em juízo, não se prestam a comprometê-los, mas lhe conferem maior certeza. Tais divergências são próprias da prova oral, dadas às notórias características da atividade policial, em particular, o envolvimento em diversas ocorrências com características semelhantes. Importa anotar, neste aspecto, que, a circunstância de o policial Odair ter sido vítima de ameaça feita pelo réu (fl. 42), fato pelo qual não foi oferecida representação por parte do miliciano, não se presta a alterar o panorama do conjunto probatório. Importa observar, a propósito, que seu testemunho é coerente com as demais provas obtidas, em especial, com o depoimento do policial Ricardo Alexandre de Oliveira" (TJ-SP - Apelação : APL 00023099020108260374 SP 0002309-90.2010.8.26.0374, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Nuevo Campos, j. em 23/10/2014, publicação em 24/10/2014).

No mesmo sentido, também merece destaque trecho de outro V. Acórdão daquele Egrégio Tribunal (TJ-SP - APL: 00092677720118260400 SP 0009267-77.2011.8.26.0400, Relator: Otávio Henrique, Data de Julgamento: 27/08/2015, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/09/2015), no qual o eminente Desembargador deixou consignado: "Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da presença de falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos. Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram. Efetivamente, 'o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.' (STF - HC nº 73.518-5, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU de 18.10.96, pág. 39.846)".

No que toca à infração penal de associação para o tráfico ilícito de drogas, por outro lado, a prova não é suficiente para a condenação, conforme, aliás, reconheceu o próprio Dr. Promotor de Justiça oficiante em seu memorial de págs. 280/285. Para a caracterização do delito de associação para o referido tráfico, exige-se que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária para a prática do

crime visado, sendo as vontades, portanto, distintas.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências, trazidas por Renato Marcão em sua obra *Tóxicos* (São Paulo : Saraiva, 6ª. ed., 2009, p. 256 e 260):

“O delito de associação para o tráfico não pode, de forma alguma, ser comparado a um mero concurso de agentes, sendo necessária para sua caracterização a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade à prática do crime visado” [TJSP, Ap. 295.901-3/1-00, 6ª Câmara, j. 6-4-2000, rel. Des. Barbosa Pereira, RT 779/571].

“Configura-se com o animus associativo, isto é, um ajuste prévio, no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdade, em que a vontade de se associar sobrepaire, mas coexista com a vontade necessária à prática do crime visado” [TJSP, Ap. Crim. 210.425-3/7, 4ª Câmara, j. 10-6-1997, rel. Des. Bittencourt Rodrigues, RT 745/539].

“Para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada” [STF, ROHC 75.236-5/AM, 1ª T., j. 3-6-1997, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 1º-8-1997, RT 749/584]” (*Tóxicos*, São Paulo : Saraiva, 6ª edição, 2009, p. 256 e 260).

Na mesma linha, leciona Damásio de Jesus:

“Elementos subjetivos do tipo

O primeiro é o dolo, vontade consciente de concretizar a associação. Há um segundo elemento subjetivo do tipo, contido na expressão 'para o fim de praticar' [crimes dos arts. 33, caput e § 1º, 34 e 36 desta Lei]. Sem a finalidade especial o fato é atípico. Nesse sentido: RT 532:381. Assim, a figura típica exige a presença do ânimo associativo, i. e., 'de um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo, uma verdadeira sociedade sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária para a prática do crime visado' [Vicente Greco Filho, *Tóxicos*, cit., 1979, p 104]” (Lei Antidrogas Anotada, São Paulo : Saraiva, 9ª ed., revista e atualizada, 2009, p. 160, sem grifos na parte final do texto).

A elementar “reiteradamente ou não”, prevista no art. 35, “caput”, não tem o significado de que toda e qualquer união destinada à prática do tráfico ilícito de drogas caracterize o delito de associação para o mesmo tráfico, pois a união, o acordo de vontades destinado ao cometimento do comércio ilícito, sem a comprovação de uma vontade distinta, organizada no sentido de constituição de uma associação voltada ao mesmo tráfico (vontade, no caso, presente na elementar “associarem-se”), caracteriza mero concurso de agentes (CP, art. 29, “caput”) destinado à realização de um dos crimes previstos nos arts. 33, “caput” e § 1º e 34, ambos de tal Lei, hipótese em que somente um destes (delitos previstos nos arts. 33, “caput” e § 1º, e 34) se consuma; e, para a caracterização da infração penal de associação para o tráfico, exige-se, consoante já exposto, um dolo distinto, separado do cometimento em si do tráfico ilícito de drogas, ainda que não haja reiteração de conduta, sendo este o significado da primeira elementar ora mencionada (“reiteradamente ou não”). São situações distintas, portanto, sendo o ato de se associar para o tráfico, o qual exige prova concreta (separada), uma coisa, e o de praticar efetivamente o tráfico ilícito, outra; caso dois ou mais agentes, por exemplo, atuem em conjunto para vender drogas, sem a constituição de uma associação destinada ao comércio ilícito, ocorre mero concurso de agentes para o cometimento do crime previsto no art. 33, “caput”, e, na hipótese de além de a venda em si da substância ilícita, eles estabelecerem um vínculo associativo, organizado, distinto, destinado às vendas, a conduta criminosa descrita no art. 35, “caput”, também se caracteriza. Aliás, sendo o momento consumativo do crime de associação para o tráfico a ocasião em que os agentes se associam para a prática dos delitos previstos nos arts. 33, “caput” e § 1º, e 34, ambos de tal Lei (conforme lição de Damásio de Jesus sobredita), o crime previsto no art. 35, “caput”, do mesmo Diploma Legal, pode ocorrer sem que o agente pratique efetivamente os crimes descritos nos dispositivos de lei supramencionados (arts. 33, “caput” e § 1º, e 34).

Quanto ao momento consumativo do crime, ensina Damásio de Jesus:

“Momento consumativo

Ocorre com a associação. Na expressão de Italo Galli, no 'momento associativo' [JTACrimSP, 54:351]. Nesse sentido: RT, 634:277; RJTJSP, 72:316; STJ, REsp 3.943, 5ª. Turma, DJU, 5 nov. 1990, p. 12437, independentemente de eventual prática dos crimes pretendidos pelo bando. Nesse sentido: RJTJSP, 69:348. Sob esse aspecto, trata-se de crime formal ou de consumação antecipada, natureza extraída do elemento subjetivo do tipo 'para o fim de...'. Nesse sentido: RJTJSP, 69:348" (op. cit., p. 161/2).

No caso presente, no entanto, não ficou comprovada a existência de uma vontade distinta, por parte dos acusados, no sentido de constituição de uma associação (é dizer, de um vínculo associativo) direcionada à prática do delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto as diligências policiais limitaram-se ao momento dos fatos e ao dia da prisão e, pelos depoimentos dos policiais, referido vínculo associativo não ficou, portanto, provado.

Para a comprovação do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, são necessários elementos concretos de prova no sentido de existência do referido vínculo (associativo) entre os agentes, tais como interceptações telefônicas anteriores ou em andamento, pedidos de busca e apreensão anterior, realizações de campanhas em datas anteriores, apreensão de eventual documentação comprobatória e até mesmo apreensão, em data anterior, de drogas pertencentes aos investigados, não bastando, desse modo, meras informações genéricas e anônimas dando conta de que os mesmos agentes/investigados vinham praticando a mercancia ilícita.

Ademais a doutrina e a jurisprudência, quase que de forma unânime, exigem a comprovação de dois requisitos para a caracterização de delito de associação para o tráfico ilícito de drogas, sendo eles estabilidade e permanência, os quais não ficaram comprovados na conduta dos acusados.

Sobre a necessidade de prova de tais requisitos (estabilidade e permanência) na espécie, segue o posicionamento da jurisprudência:

"Apelações do Ministério Público e de um dos réus - Tráfico de entorpecente e associação para tal delito. Insurgência ministerial que se restringe à absolvição dos réus da associação - Ausência de estabilidade e de ânimo subjetivo - Precedentes - Absolvição que se mantém. Defesa que busca a absolvição, desclassificação da conduta para uso pessoal ou redução das penas - Acusados apanhados com 18 pinos de cocaína (11,23g) - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho de agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Desclassificação para uso pessoal - Impossibilidade - Finalidade mercantil - Pena mínima reduzida de 1/6, nos termos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, conformada a acusação nesse ponto - Regime fechado - Necessidade. Recursos não providos" (TJ-SP - APL: 00000565820148260417 SP 0000056-58.2014.8.26.0417, Relator: Ivan Sartori, Data de Julgamento: 15/09/2015, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/09/2015).

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉUS QUE TRANSPORTAVAM E GUARDAVAM 11 PORÇÕES DE MACONHA, PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÕES MANTIDAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE FABRICAÇÃO, PRODUÇÃO, PREPARO OU TRANSFORMAÇÃO DE ENTORPECENTES - CONDUTAS NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS - OBJETOS APREENHIDOS QUE SE DESTINAVAM À SEPARAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DOS TÓXICOS - ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 34 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DO REDUTOR, PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS PARA O RÉU NIVALDO - POSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO" (TJ-SP - APL: 30038922720138260286 SP 3003892-27.2013.8.26.0286, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 29/10/2015, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/11/2015).

No mesmo sentido, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

"101. Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos no arts. 33, caput, e § 1.º, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei

6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico. Demanda-se a prova da estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa. Nesse prisma: STJ: 'O crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06 exige que a associação entre os agentes ocorra de forma estável ou em caráter permanente, caracterizando a reunião eventual mero concurso de pessoas. No caso, tendo as instâncias ordinárias, após exame das provas dos autos, constatado a existência de estabilidade e permanência entre o agravante e outros indivíduos, inviável a reversão do julgado ante o óbice constante da Súmula 7/STJ.' [AgRg no AREsp 303.213/SP, 5.^a T, rel. Marco Aurélio Bellizze, DJ 08.10.2013]; 'O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos art. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. II- De outro lado, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo, sendo prescindível para a sua configuração efetiva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006.' [REsp 1.113.728-SC, 5.^a T., rel. Felix Fischer, 29.09.2009, v.u.]. TJDF: 'O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1.º, e artigo 34 do mesmo diploma legal. assim, diante das provas do animus associativo de caráter estável e duradouro entre o apelante e os codenunciados, inviável o pleito absolutório quanto ao delito de associação para o tráfico, especialmente pelas declarações prestadas pelos policiais, corroboradas pelas interceptações telefônicas.' [Apelação 20100112165299APR, 2.^a Turma Criminal, rel. Roberval Casemiro Belinati, DJ 20.03.2014]. TJSP: 'Acusados que se cooperavam, agindo mutuamente, ainda que eventualmente, na prática do comércio de entorpecentes. Insuficiência de provas - Acolhimento Não configurada a estabilidade e permanência do vínculo subjetivo. Absolvição que se impõe. Recursos defensivos providos.' [Apelação 0029273-41.2010.8.26.0562, 4.^a Câmara Criminal Extraordinária, rel. César Augusto Andrade de Castro, DJ 27.03.2014]. TJMG: 'A atuação das rés em 'societas sceleris', realizando, de forma estável e permanente, um programa delinquencial e praticando crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, especialmente da droga denominada cocaína, dá ensejo à condenação pelo delito tipificado no art. 14 da Lei 6.368/76 [revogada].' [Ap. 1.0324.03.016270-9, rel. Paulo César Dias, 23.11.2004, DJ 25.02.2005]..." (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol. 1, Rio de Janeiro : GEN/Forense, 8.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 361/2). Dessa forma, quanto ao tal ponto da acusação, deve militar, em favor dos acusados, o princípio "in dubio pro reo", pelo qual a dúvida favorece o agente. O decreto condenatório, somente quanto aos delitos de tráfico ilícito de drogas (quanto aos dois acusados) e resistência (Kléber Alfredo), pois, é de rigor. Passo à dosagem da pena.

a)- Eduardo Fernando:

Na primeira fase, levando-se em conta os péssimos antecedentes (processos nºs. 0000971-94.2011.8.26.0132, 0001676-63.2009.8.26.0132, 0003679-54.2010.8.26.0132 e 3002422-35.2013.8.26.0132 - págs. 59/62), fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/5 (um quinto). Tratando-se de agentes de péssimos antecedentes, adequado o aumento da pena em 1/5 (um quinto).

Nesse sentido:

"FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Escalada e concurso de agentes. Autoria e materialidade delitivas comprovadas, sobretudo pela confissão, corroborada por outros elementos seguros de prova. Qualificadoras bem caracterizadas. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas corretamente acrescidas de um quinto em razão dos péssimos antecedentes e do reconhecimento de uma qualificadora como circunstância judicial desfavorável. Na fase seguinte, penas que devem ser majoradas de um quinto, e não de um terço, diante da compensação parcial da agravante da múltipla reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Inocorrência de arrependimento posterior. Regime fechado inalterado. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos em razão dos maus antecedentes e da múltipla reincidência. Apelo parcialmente provido para redução das penas" (TJSP; Apelação Criminal 0000515-45.2016.8.26.0270; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeva - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020).

Na segunda fase, tendo em vista a agravante genérica da reincidência (processo nº 0000265-55.2015.8.26.0558 - pág. 59, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo Diploma Legal, ante os péssimos antecedentes e a reincidência do acusado.

Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva e pena em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira - interrogatório judicial e informações sobre a vida pregressa de pág. 11).

O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista a gravidade concreta da infração penal, uma das que mais afetam a paz pública nos dias atuais, e os péssimos antecedentes e a reincidência do acusado, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime.

b)- Kléber Alfredo:

b.1)- tráfico ilícito de drogas:

Na primeira fase, levando-se em conta os péssimos antecedentes (processos nºs. 0009389-73.2007.8.26.0451 e 0009688-79.2009.8.26.0451 - págs. 77/78), fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/5 (um quinto).

Tratando-se de agentes de péssimos antecedentes, adequado o aumento da pena em 1/5 (um quinto), conforma já exposto na dosimetria da pena do outro acusado.

Na segunda fase, tendo em vista a agravante genérica da reincidência, no caso específica (processo nº 0002280-57.2011.8.26.0648 - pág. 78, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo Diploma Legal, ante os péssimos antecedentes e a reincidência específica do acusado.

Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva e pena em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira - interrogatório judicial e informações sobre a vida pregressa de pág. 10).

O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista a gravidade concreta da infração penal, uma das que mais afetam a paz pública nos dias atuais, e os péssimos antecedentes e a reincidência específica do acusado, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime.

b.2)- resistência:

Na primeira fase, levando-se em conta os péssimos antecedentes (processos nºs. 0009389-73.2007.8.26.0451 e 0009688-79.2009.8.26.0451 - págs. 77/78), fixo a pena-base em 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, mínima legal acrescida de 1/5 (um quinto).

Tratando-se de agentes de péssimos antecedentes, adequado o aumento da pena em 1/5 (um quinto), consoante já exposto.

Na segunda fase, tendo em vista a agravante genérica da reincidência (processo nº processo nº 0002280-57.2011.8.26.0648 - pág. 78, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), para 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, a qual torno definitiva na

ausência de outras circunstâncias ou causas de modificação.

O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista os péssimos antecedentes e a reincidência do acusado, será o semiaberto, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime.

Pelos mesmos motivos (péssimos antecedentes e reincidência), nego-lhe a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou pela multa vicariante prevista no art. 44, § 2º, do Código Penal, bem como o "sursis".

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública para o fim de: CONDENAR EDUARDO FERNANDO FUZARO e KLÉBER ALFREDO TORRES, qualificados, respectivamente, às págs. 6 e 7, como incursos no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c. c. o art. 29, "caput", do Código Penal, ambos à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção já mencionada; b)- CONDENAR KLÉBER ALFREDO TORRES como incurso no art. 329, "caput", do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; e c) ABSOLVER ambos os acusados da imputação do art. 35, "caput", da mesma Lei, absolvição que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código Penal.

Condeno os acusados, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima Everton Rogério (resistência), porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, porque, se eles permaneceram presos durante toda a instrução criminal, não há sentido para que, agora, já com sentença condenatória em primeira instância, sejam beneficiados pela liberdade provisória nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados na Decisão de págs. 99/101.

Decreto a perda, em favor da União, de todo o valor apreendido e depositado nos autos (referente a dinheiro), nos moldes do art. 63, § 1º, da Lei sobredita.

Autorizo, com o trânsito em julgado, a destruição das anotações em papel (pág. 50).

Já houve autorização para destruição das drogas (pág. 101).

Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como a transferência do valor depositado em Juízo ao "Funad" (Lei nº 11.343/2006, art. 62, § 9º); oficie-se à D. Autoridade Policial autorizando a destruição do restante da droga armazenado para eventual contraprova; e oficie-se à Autoridade que detiver a guarda das anotações em papel (pág. 50) comunicando que a destruição delas também está autorizada.

A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram e expeçam-se guias de execução provisória, com urgência e prioridade.

P. I. C.

Catanduva, 16 de abril de 2022.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA